

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

刑法学

(上册·总论)
(第二版)

《刑法学》编写组

第十章 故意犯罪的停止形态

 高等教育出版社

目 录

1

第一节

故意犯罪停止形态概述

2

第二节

犯罪既遂形态

3

第三节

犯罪预备形态

4

第四节

犯罪未遂形态

5

第五节

犯罪中止形态

第十章 故意犯罪的停止形态

/10

第一节

故意犯罪停止形态概述

一、故意犯罪停止形态的概念与特征

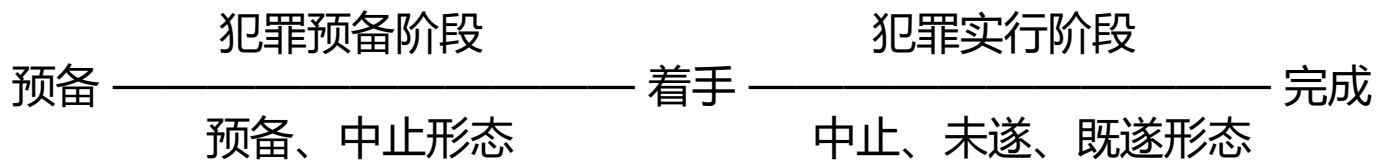
（一）故意犯罪停止形态的概念

故意犯罪停止形态，是指部分故意犯罪在实施过程中，由于主客观原因停止后所呈现的各种具体状态（故意犯罪在产生、发展和完成的过程中，由于主客观原因而停止下来的各种犯罪形态），包括完成形态与未完成形态两种类型。

具体包括四种形式：犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止与犯罪既遂。

（二）故意犯罪停止形态的特征

- 1.故意犯罪停止形态只能存在于部分直接故意犯罪中（一种特定犯罪只有一种停止形态）。
- 2.故意犯罪停止形态只能发生在犯罪过程中（故意犯罪的停止形态与故意犯罪的过程、阶段有所区别）。
- 3.故意犯罪停止形态是一种结局性的状态（故意犯罪过程中不再发展、固定下来、相对静止的不同结局）。



二、故意犯罪停止形态的存在范围

（一）过失犯罪不存在犯罪停止形态

过失犯罪在主观上具有非故意的心理，在客观上以危害结果的发生为构成要件，所以，不存在犯罪的未完成形态。同时，犯罪的未完成形态是与犯罪的完成形态相对而言的，对过失犯罪没有讨论犯罪既遂的意义。

（二）间接故意犯罪也不存在犯罪停止形态

间接故意犯罪在主观上具有放任心理，不符合未完成形态犯罪的被迫性或自愿性的心理；在客观上，无论危害结果是否发生均符合其心理，因而没有根据危害行为认定其犯罪形态的可能。因此，间接故意犯罪也不存在犯罪停止形态。

（三）并非所有的直接故意犯罪都存在犯罪停止形态

- 1.举动犯：不存在犯罪未遂形态（？）
- 2.情节犯：不存在犯罪未遂形态（？）
- 3.结果加重犯：不存在犯罪停止形态（？）
- 4.突发性的直接故意犯罪：只存在犯罪既遂、犯罪未遂和犯罪中止（实行阶段）形态

三、故意犯罪停止形态与犯罪构成的关系

作为主客观要件统一体的犯罪构成是所有犯罪的成立规格与认定标准，是判断某种行为是否构成犯罪的唯一根据。

既遂犯符合的基本的犯罪构成，预备犯、未遂犯和中止犯符合的是修正的犯罪构成。修正的犯罪构成主要是对基本犯罪构成的客观方面、主体等要件进行修正、变更后而确定的。

因此，未完成犯罪负刑事责任的根据就在于其行为符合修正的犯罪构成。

第十章 故意犯罪的停止形态

/10

第二节

犯罪既遂形态

一、犯罪既遂形态的概念

犯罪既遂是指实行直接故意犯罪之后具备了完备犯罪构成要件之全部要素的故意犯罪形态。

结果说	目的说	构成要件说
以故意犯罪行为是否发生构成要件结果为标准	以故意犯罪行为是否达到犯罪目的为标准	以故意犯罪行为是否具备全部犯罪构成要件为标准
仅适用于结果犯の場合	仅适用于目的犯の場合	提出了认定犯罪既遂的统一标准，基本可取

第一，必须具有直接故意。

第二，必须已经着手实行犯罪。

第三，必须具备了某种犯罪构成的全部要件。

既遂犯=直接客体+犯罪客观方面+直接故意+犯罪主体

二、犯罪既遂形态的类型

(一) 结果犯：以法定的犯罪结果的发生与否作为既遂与未遂区别标志的犯罪

(二) 行为犯：以法定的犯罪行为的完成作为既遂标志的犯罪

(三) 危险犯：以行为人实施的行为造成法律规定的发生某种危害结果的危险状态作为既遂标志的犯罪 (张明楷：《刑法学》(上 第六版)，p214—215)

(四) 举动犯：按照法律规定，行为人一经着手实行即成立既遂的犯罪

三、既遂犯的处罚原则

对于犯罪既遂，我国刑法总则没有专门规定其处罚原则。对于既遂犯的处罚，可结合刑法总则的有关规定（如罪责刑相适应原则），直接按照刑法分则具体条文规定的法定刑幅度进行裁量。

第十章 故意犯罪的停止形态

/10

第三节

犯罪预备形态

一、犯罪预备形态的概念与特征

犯罪预备形态，是指为了实行犯罪而准备工具、制造条件，但基于行为人意志以外的原因而停止在犯罪预备阶段的形态（行为人为实施犯罪而准备工具、创造条件，但由于其意志以外的原因而未能着手犯罪的实行行为）。

（一）行为人主观上是为了实行犯罪

要成立犯罪预备形态，首先行为人主观上必须具有犯罪意图（为了顺利地实施及完成犯罪），主观犯罪意图是犯罪预备形态与一般日常生活行为的根本区别，也是刑法处罚预备犯的主要根据。

一、犯罪预备形态的概念与特征

（二）客观上实施了犯罪预备行为

根据我国刑法规定，成立犯罪预备形态在客观上必须实施了犯罪预备行为，没有实施这一行为，而只是单纯地向他人表示想要犯罪的意思的，不能认定为预备犯。

预备犯罪行为分为以下两类：

- 1.为犯罪准备工具。
- 2.为犯罪制造条件（如“踩点”）。

一、犯罪预备形态的概念与特征

（三）行为停止在犯罪的预备阶段

犯罪预备形态只能发生在着手实行犯罪之前的犯罪预备阶段（即尚未着手犯罪的实行行为），这是犯罪预备和犯罪未遂的主要区别。

1. 预备行为尚未实施终了。
2. 预备行为已经实施终了但尚未着手实行犯罪。

（四）行为系基于行为人意志以外的原因而停止下来

第一，行为人在犯罪预备过程中基于自己的意志主动放弃预备行为的，或者在预备行为终了后出于自觉自愿停止下来而不再着手实行犯罪的，都不是预备犯。

第二，只有对基于行为人意志以外的原因而停止在预备阶段的，才能认定为预备犯。

- (1) 作案条件不成熟
- (2) 被害人闻讯逃避
- (3) 被害人不在现场
- (4) 公安机关及时行动
- (5) 被他人制止

二、预备犯的处罚原则

对于预备犯，我国刑法的立场是原则上应予以处罚。

- (一) 只有在预备犯侵害特别重要的客体如国家安全、公共安全、生命权、健康权等场合，才能受到处罚

- （二）对预备犯量刑时，所比照的既遂犯应当是预备犯向前发展可能形成的或必将出现的既遂犯
- （三）当预备犯与实行犯竞合时，按照想象竞合犯的处断原则处理
- （四）预备犯的社会危害性通常小于未遂犯的社会危害性，对其处罚应当轻于未遂犯
- （五）综合考虑预备犯意图实施的犯罪性质、预备行为的进展情况和危害程度、行为人未能着手的原因及其人身危险性等因素，对其予以从宽处罚

第十章 故意犯罪的停止形态

/10

第四节

犯罪未遂形态

一、犯罪未遂形态的概念与特征

犯罪未遂或者未遂犯是指行为人已经着手实行犯罪，基于其意志以外的原因而未能完成犯罪的故意犯罪停止形态。

（一）行为人已经着手实行犯罪

是否着手实行犯罪，是犯罪预备阶段与犯罪实行阶段的分界线，也是区分预备犯与未遂犯的标志。

着手是指行为人决意实施刑法分则规定的具有实现犯罪构成所要求的结果可能性的行为。

在主观层面，行为人决意实施犯罪实行行为；

在客观层面，行为人所实施的行为是具备实现构成要件所要求的结果可能性的行为（在形式上，行为已经开始实施犯罪构成客观方面的行为；在实质上，行为人实施的实行行为具有侵害刑法所保护的社会关系的现实危险性）；

在后果层面，行为人着手实行犯罪后，其行为对刑法所保护的客体具有现实的危害和威胁。

（二）犯罪未得逞

犯罪未得逞，是指犯罪行为没有完整具备刑法分则规定的某一犯罪构成的要件（即指法定的危害结果没有发生、法定的犯罪行为没有完成或法定的危险状态没有出现）。

学说争议：“法定结果说” “目的说” “构成要件齐备说”（通说）

（三）犯罪未得逞是基于犯罪人意志以外的原因

犯罪人意志以外的原因，是指违背犯罪人本意的客观情况阻止犯罪行为达到既遂，或者使犯罪人认为不能既遂从而停止犯罪的原因（即足以阻止犯罪意志的原因。在性质上，它是阻碍犯罪实行、完成的意志因素，包括行为人本人以外的原因、行为人自身方面的因素以及行为人主观上的认识错误。在程度上，它达到了能够阻止犯罪完成的程度，但并非所有对犯罪完成有不利影响的因素，都能达到阻止犯罪完成的程度）。

犯罪未得逞的原因可以归纳为以下三种类型：

1. 行为人自身以外的原因。

① 受到自然力的破坏

② 遇到被害人的强烈反抗

③ 被害人有效逃避

④ 公安机关及时行动

⑤ 被第三者制止

⑥ 客观条件使犯罪难以继续进行

⑦ 碰到难以克服的物质障碍

2.行为人本身能力的原因。

①临场紧张

②技术拙劣

③突遇病变

④体力不济

3.行为人主观认识错误的原因。

①对犯罪对象的认识错误

②对犯罪工具的认识错误

③对因果关系的认识错误

④对客观环境的认识错误

二、犯罪未遂形态的种类

（一）以实行行为是否实行终了（罪犯是否自认为实现犯罪意图所必要的全部行为都实行完毕）为标准，区分为实行终了的未遂与未实行终了的未遂

1.实行终了的未遂是行为人已将自认为达到既遂所必需的全部行为实行终了，但基于意志以外的原因未得逞。

2.未实行终了的未遂则是基于意志以外的原因，行为人未能将他认为达到既遂所必需的全部行为实行终了，因而未得逞。

（二）以行为本身能否既遂为标准，区分为能犯未遂与不能犯未遂

能犯未遂是指犯罪行为有可能达到既遂，但基于行为人意志以外的原因未能达到既遂而停止

下来的情况。

不能犯未遂是指根据案件的具体事实，行为人所实施的行为本身就不可能达到既遂的情况。

不能犯未遂又可以分为对象不能犯未遂和工具不能犯未遂。

(1) 对象不能犯未遂，是指由于行为所指向的对象不在行为的有效作用范围之内，或者不具有特定犯罪对象的属性，从而使得犯罪不能既遂。

(2) 工具不能犯未遂，是指行为人所使用的犯罪工具没有效果而使得犯罪不能既遂。

(3) 迷信犯是行为人出于愚昧无知的迷信思想，采用实际上根本不可能发生危害结果的方法加害他人的情况。

我国刑法学通说并没有单独的不能犯概念，而仅存在与能犯未遂相对应的不能犯未遂的概念。

不能犯是日本刑法学讨论的一种样态，其将不能犯和未遂犯加以区分。

日本刑法学界区分不能犯和未遂犯的标准有客观危险说、主观说、抽象危险说和具体危险说等观点 (p227-228) 。

日本刑法学界区分不能犯和未遂犯的标准是否科学值得进一步探讨，我们应该按照我国刑法的社会危害性理论进行判断。如果不能犯行为具有严重的社会危害性，则应该成立犯罪未遂；倘若这种行为不具有严重的社会危害性，则不能成立犯罪。具体判断标准如下：

第一，不能犯未遂行为应当具有实现构成要件结果的可能性即现实危险性 (结果发生的远近) 。

第二，不能犯未遂行为应当具有实现构成要件结果的高度盖然性 (结果发生的高低) 。

第三，行为所实现的构成要件结果应该是严重的结果 (结果发生的程度) 。

第四，是否存在实现严重犯罪构成要件结果的危险性，由法官按照与行为人同一类型的人行为时的一般立场进行事后判断。

三、未遂犯的处罚原则

（一）刑法规定

《刑法》第23条第2款：“对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。”

（二）理解

第一，在其他情节相同的情况下，犯罪未遂的社会危害性较犯罪既遂要轻一些，因而在处罚时要充分考虑两者的区别，对未遂犯适当从宽掌握。

第二，对犯罪未遂在处罚时是“可以”从宽而不是必须从宽。

第三，未遂犯的从宽幅度为“从轻或者减轻处罚”（综合考虑未遂犯意图实施的犯罪性质、未遂行为的进展情况、危害程度和所属类型、行为人的主观恶性等因素）。

第四，对未遂犯，在把握从宽的尺度时应比预备犯严。

第十章 故意犯罪的停止形态

/10

第五节

犯罪中止形态

一、犯罪中止形态的概念与特征

犯罪中止形态是指在犯罪过程中，行为人自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生，而未完成犯罪的一种故意犯罪停止形态。

（一）自动停止犯罪的犯罪中止形态的特征

1.犯罪中止必须发生在“犯罪过程中”。

所谓“犯罪过程中”，是指从犯罪预备行为发生开始，到犯罪既遂状态以前这段时间内，犯罪处于运动中尚未停止下来而呈现出预备或未遂形态。

2.客观上存在放弃犯罪的中止行为。

所谓放弃犯罪，是指在犯罪过程中停止实施犯罪，因而犯罪构成所规定的危害结果不会发生的情形。

（一）自动停止犯罪的犯罪中止形态的特征

3. 行为人放弃犯罪是基于自己意愿的自动为之。

所谓自动性，应被理解为行为人主动放弃犯罪，即在没有任何外界因素阻止下，行为人出于自己的意志而停止犯罪（出于自己的意志放弃了自认为当时本可继续实施和完成的犯罪）。

（1）自认为当时可继续实施和完成犯罪

即使在他人看来不可能继续实施和完成犯罪，或犯罪在客观上已不能再继续实施和完成，也成立自动性；反之，如果行为人对上述情况产生误认，就缺乏自动性。

（2）出于本人意志而停止犯罪

行为人基于上述认识，选择放弃犯罪。对行为人放弃犯罪的动机应作广义的理解，并不

要求其必须出于高尚的道德动机而停止犯罪。因此，自动性首先意味着行为人在确信能够完成犯罪的前提下，不想继续犯罪。反之，假如行为人已对犯罪的前景感到失望、绝望，不管其主观认识与客观事实是否一致，都不具备中止性。

在存在外界因素影响的场合，应当结合行为人的认识情况和外界因素的表现形式，分别认定是否存在自动性（张明楷：《刑法学》（上 第六版），p470—474）：

第一，是否基于悔悟、同情等对自己的行为持否定评价的规范意识、感情或动机而放弃犯罪（伦理上，如暴力殴打被害人后，发现其非常痛苦而停止伤害行为）。

第二，是否基于对外部障碍的认识，认为可能达到既遂而不愿达到既遂而放弃犯罪（心理上，如准备多种凶器杀人，在一种凶器不起作用时停止行为）。

第三，是否因为在当时的情况下，一般人不会放弃犯罪而行为人会放弃犯罪，从而表明其没有特殊预防的必要性（规范上，如晚上意欲奸淫妇女，突然发现对方是熟人而停止行为？）。

4.中止行为具有彻底性。

所谓中止行为的彻底性，是指行为人主观上彻底放弃犯罪，而不是暂时停下来等待犯罪时机成熟之后再继续犯罪。

（二）自动有效地防止犯罪结果发生的犯罪中止形态的特征

所谓自动有效地防止犯罪结果发生的犯罪中止形态，是指在着手实行犯罪之后，行为人已实施的犯罪行为可能造成但尚未造成构成要件所规定结果的情况下，行为人采取措施有效地阻止该危害结果发生的一种故意犯罪停止形态。其特征包括：

- 1.行为发生在实行阶段并有发生既遂之危害结果的可能性。
- 2.实施了防止犯罪结果发生的中止行为。
- 3.中止行为的自动性。

所谓自动性，是指行为人基于自己的意志中止犯罪的情形。

- 4.中止行为的有效性。

中止行为的有效性是指没有发生行为人之前所追求的、由行为性质决定的危害结果，而不是说未发生任何危害结果。

争议问题：自动放弃可能重复的侵害行为，成立犯罪中止还是未遂？

（1）概念

自动放弃可能重复的侵害行为，是指行为人在着手实行犯罪行为一次或多次后，未造成构成要件所规定的危害结果，行为人认识到可以继续实施侵害行为，而此时行为人自动放弃可能重复的侵害行为的情形。

第一，发生在犯罪未实行终了的过程中。

第二，放弃可能重复侵害的（同一性质的）行为是自动的。

第三，犯罪结果没有发生。

（2）争议： 第一，犯罪未遂； 第二，犯罪中止。

社会应该在法律允许的限度内更多地为中止犯罪的行为人重新顺利回归社会搭建起金桥（**责任减少+特殊预防**）。

二、中止犯的处罚原则

（一）刑法规定

《刑法》第24条第2款：“对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。”

（二）理解

第一，对于中止犯，在处罚时必须从宽。

第二，中止犯的法定从宽标准为免除处罚和减轻处罚两种，而不包括从轻处罚。

第三，对具体中止犯究竟是免除处罚还是减轻处罚，应以犯罪中止形态是否造成损害为根据。

第四，只有当行为符合某种重罪的中止犯的成立条件，同时又构成某种轻罪的既遂犯时，才

能认定为“造成损害”。

第五，对造成损害的中止犯减轻处罚，实际是对中止前行为构成的轻罪既遂犯进行处罚，此时既要受《刑法》第63条的制约，也要与轻罪的法定刑及其量刑实践相协调。



思考题

- 1.故意犯罪停止形态与故意犯罪阶段有何联系与区别？
- 2.结果犯与行为犯在既遂形态上有何不同？
- 3.怎样区分犯罪预备形态与单纯犯意表示？ 如何理解预备犯的处罚原则？
- 4.如何认定实行行为的“着手”？
- 5.试述我国处罚不能犯未遂的具体根据。
- 6.自动停止犯罪之后采取措施阻止危害结果出现，但是危害结果系基于其他原因而未发生的，应当认定为犯罪中止还是犯罪未遂？